

1502439-92.2021.8.26.0156

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... que confirmado em juízo.

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO.

NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Cruzeiro-SP - cep 12710-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502439-92.2021.8.26.0156 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502439-92.2021.8.26.0156

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2280623/2021 - DEL.INV.GER. CRUZEIRO, 15132318 - DEL.INV.GER. CRUZEIRO, 844/21/103

- DEL.INV.GER. CRUZEIRO, 2280623 - DEL.INV.GER. CRUZEIRO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

A SER IDENTIFICADO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu(sua) representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia WILLIAN DE OLIVEIRA FERREIRA, como incurso(s) na prática do(s) delito(s) tipificado(s) no art. 157, "caput", c.c art. 61, inciso II, "j" (calamidade pública), ambos CP Narra a denúncia que, no dia 08 de outubro de 2021, por volta das 20h40, em meio à situação de calamidade pública decorrente da pandemia (Covid19), na Avenida Governador Jânio Quadros, n.611, Vila Dr. João Batista, nesta cidade e Comarca de Cruzeiro/SP, WILLIAN DE OLIVEIRA FERREIRA, vulgo "Willian do Postinho", qualificado e ouvido à fl. 40, subtraiu para si, mediante grave com simulacro de arma de fogo, um celular Samsung A02 (avaliado em R\$ 750,00, cf. auto de fl. 37), um documento de

identidade (RG) e um cartão bancário, em prejuízo da vítima Jennifer Eleen Fernandes Manoel.

Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e espaço acima referidas, durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia (Covid19), com menor circulação de pessoas e redução do policiamento em virtude de restrições sanitárias, o denunciado deliberou subtrair o patrimônio alheio.

Para tanto, se aproximou da vítima de bicicleta, em via pública, e a surpreendeu pelas costas, ameaçando-a com um simulacro de arma de fogo ("aparentando ser uma pistola" - fl. 05) e exigindo que ela entregasse o aparelho celular, cuja capa continha RG e cartão bancário. Após subtrair os objetos, o implicado fugiu de bicicleta, na posse da "res furtiva".

Na semana seguinte, a vítima retornou à Delegacia de Polícia, noticiando que moradores do bairro lhe informaram que o autor do assalto seria "William do Postinho", tendo se dirigido à residência de uma tia do suspeito e obtido fotografias (fls. 08), pelas quais identificou, sem sombra de dúvidas, William como sendo o autor do crime.

Registre-se que, em 29 de novembro de 2021, durante busca e apreensão realizada na residência do denunciado em virtude de outro roubo com igual "modus operandi" (autos n. 1502563-75.2021.8.26.0156), os policiais localizaram um simulacro de "arma de fogo, que imitava uma pistola" (cf. documento 1). Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

Audiência de instrução e julgamento realizada em 28 de julho de 2022, onde foi ouvida a vítima, as testemunhas e, ao final, interrogado o réu.

As partes apresentaram suas alegações finais.

O Ministério Público pediu a procedência da denúncia nos exatos termos em que formulada.

A Defesa apresentou suas alegações finais por escrito (fls. 140/151).

Enfim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

PRELIMINARES

NULIDADE DA PROVA E DA AÇÃO PENAL CORRELATA

A combativa defesa sustenta que, em razão do reconhecimento realizado em solo policial não ter observado as formalidades estabelecidas na legislação processual penal, tal procedimento é nulo e macula todo o inquérito policial e, via de consequência, a ação penal.

Nesse ponto, não assiste razão à defesa.

Primeiramente, cumpre salientar que o inquérito policial é um procedimento administrativo inquisitório e preparatório, presidido pela autoridade policial, consistente em um conjunto de diligências realizadas pela polícia investigativa objetivando a identificação das fontes de prova e a colheita de elementos de informação quanto à autoria e materialidade da infração penal, a fim de possibilitar que o titular da ação penal possa ingressar em juízo.

Trata-se de um procedimento de natureza instrumental, porquanto se destina a esclarecer os fatos delituosos relatados na notícia de crimes, fornecendo subsídios para o prosseguimento ou o arquivamento da persecução penal.

Logo, como o inquérito policial é mera peça informativa, eventuais vícios dele constantes não têm o condão de contaminar o processo penal a que der origem.

Havendo, assim, eventual irregularidade em ato praticado no curso do inquérito, mostra-se inviável a anulação do processo penal subsequente.

Ao longo do inquérito policial são obtidos elementos de informação que irão subsidiar o titular da ação penal, neste caso, o Ministério Público, a formar sua opinio delicti.

Elementos de informação são aqueles colhidos na fase investigatória, sem a obrigatoria observância do contraditório e da ampla defesa.

Salienta-se, ainda, que os elementos de informação não podem, de forma isolada, embasar um decreto condenatório.

Tendo em conta que esses elementos de informação não são colhidos sob a égide do contraditório e da ampla defesa, deduz-se que o inquérito policial tem valor

probatório relativo.

Como já se manifestou o STF, os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios que passam pelo crivo do contraditório em juízo.

Portanto, analisando as teses processuais levantadas pela defesa, observa-se que eventual irregularidade na obtenção de tais elementos de informação, não tem o condão de macular o andamento da ação penal respectiva.

Assim, eventuais irregularidade não contaminam o andamento da ação penal, devendo a qualidade e profundidade dos elementos de informação serem analisando em conjunto com as demais provas obtidas, matéria essa afeta ao mérito da ação penal.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. TESE DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE E DA AMPLA DEFESA. ARTS. 34, XX, E 202 DO RISTJ. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTO-INCRIMINAÇÃO. DEPOIMENTO E DOCUMENTOS FORNECIDOS NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA. NÃO VERIFICADA. DENÚNCIA LASTREADA EM ELEMENTOS AUTÔNOMOS. PRINCÍPIO DA AQUISIÇÃO PROCESSUAL OU DA COMUNHÃO DA PROVA. INQUÉRITO POLICIAL. NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA. VÍCIOS QUE NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "o Regimento Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ)" (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/RR, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/5/2017).

II - Os artigos 34, inciso XX, e 202, ambos do RISTJ, atribuem ao Relator a competência para "decidir o habeas corpus quando for inadmissível, prejudicado ou quando a decisão impugnada se conformar com tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência dominante acerca do tema ou as confrontar".

III - A interposição do agravo regimental torna superada a alegação de afronta aos princípios do juiz natural e da colegialidade e torna prejudicados eventuais vícios relacionados ao julgamento monocrático, tendo em vista que, com o agravo, devolve-se ao órgão colegiado competente a apreciação do mérito da ação, do recurso ou do incidente.

IV - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

V - In casu, sustenta-se a nulidade da Ação Penal n.

5030173-60.2016.4.04.7000/PR, com base no argumento de que todos os elementos de informação nos quais se lastreou a peça acusatória teriam sido obtidos em violação ao princípio da não auto-incriminação, visto que teriam sido fornecidos exclusivamente pela recorrente na condição de testemunha, compromissada a dizer a verdade e sem que lhe fosse garantido o direito de permanecer em silêncio, embora a autoridade policial e o Ministério Público Federal, em tese, por ocasião da oitiva, já tivessem convicção formada quanto à sua participação em fatos investigados na Operação Lava Jato.

VI - Em juízo de cognição sumária, próprio ao habeas corpus, verifica-se que a formulação da opinio delicti do órgão acusatório e as decisões das instâncias precedentes fundamentaram-se em elementos independentes das declarações e do material apresentado pela recorrente no curso do inquérito policial. Ao contrário, nota-se que o depoimento e os documentos por ela apresentados na etapa inquisitória encerraram importância apenas secundária ou acessória na fundamentação da decisão que admitiu a peça acusatória.

VII - De acordo com o princípio da aquisição processual ou da comunhão da prova, as

provas com que a parte instrui os autos - aí incluídos os documentos - passam a pertencer ao processo e, nessa medida, podem ser empregadas para a persuasão racional do magistrado independentemente de quem a tenha produzido. Desse modo, a fundamentação das decisões das instâncias ordinárias com base em documentos fornecidos pela recorrente em sede de contrarrazões apresentadas em recurso em sentido estrito não pode ser interpretado como violação ao princípio da não auto-incriminação.

VIII - Eventual nulidade na oitiva da recorrente no curso da investigação preliminar não tem o condão de nulificar o recebimento da denúncia e a ação penal deflagrada, tendo em vista que, por um lado, existem elementos autônomos que sustentam as decisões impugnadas; e, por outro, eventuais vícios na fase extrajudicial não contaminam o processo penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 124.024/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020) (grifo nosso)

Portanto, rejeito a preliminar levantada.

No mais, o feito encontra-se em ordem. Não há outras preliminares a dirimir.

Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais.

Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

No mérito, a ação penal é IMPROCEDENTE.

Com efeito, analisando atentamente o acervo probatório, e considerando os elementos indiciários existentes nos autos, verifica-se não haver prova suficiente para embasar um decreto condenatório, devendo ser o acusado ser absolvido dos delitos imputados.

A materialidade delitiva resultou provada pelo boletim de ocorrência (fls. 3/4), Termo de Declarações da Vítima Jennifer (fl. 05), bem como pela prova oral colhida. A autoria, todavia, não restou suficientemente demonstrada.

A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça colocou um fim ao entendimento de que as formalidades exigidas pelo art. 226, do CPP são apenas meras sugestões procedimentais.

O reconhecimento do suspeito de um crime por mera exibição de fotografias há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

O art. 226 do CPP admite o reconhecimento de pessoa e impõe o seguinte procedimento para sua validade:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, assinado pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Relator, o ministro Rogerio Schietti destacou que essas formalidades são essenciais para o processo.

O Superior Tribunal de Justiça então fixou as seguintes diretrizes:

1. O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime

2. À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo

3. Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que

observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitativa a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento

4. O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s), ao reconhecer, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO.

NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitativa, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, conseqüentemente, causar erros judiciais de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis. 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitativa. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. 4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato. 5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das conseqüências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciais e, conseqüentemente, de graves injustiças. 6. É de se exigir que as polícias judiciárias (cíveis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a "defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia" (art. 129, II). 7. Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial

fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado. 8. Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo "processualmente admissível e válido" (Figueiredo Dias). 9. O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento - sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo - ficam mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado 10. Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado. 11. Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito - conforme reconheceu o Magistrado sentenciante - emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância). 12. Conclusões: 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. STJ HC 598.886/SC. 6ª TURMA. REL. MIN. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. JULGADO EM 27/10/2020.

No caso dos autos, a fim de se verificar a certeza necessária a respeito da autoria delitiva procedeu-se ao reconhecimento pessoal (virtual) em audiência de instrução e julgamento. O réu foi colocado lado a lado com outras duas pessoas de características semelhantes.

Contudo, a vítima não pode atestar com certeza quem seria o autor do delito. Além do mais, após insistência deste magistrado, ela apontou o indivíduo de número 3, ao passo que o réu estava identificado com o número 01.

Primeiramente, antes do início da oitiva das testemunhas, cumpre salientar que o réu foi reconhecido, sem qualquer dúvida, pela vítima como sendo o autor dos fatos denunciado.

O réu foi colocado lado a lado com outros dois indivíduos, com características físicas semelhantes, sendo reconhecido positivamente pela vítima, seguindo o estabelecido pelo art. 226, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, a vítima Jennifer por sua vez, apesar de ter reconhecido o acusado na delegacia de polícia com absoluta certeza, em Juízo indicou outra pessoa como o

roubador.

Durante o contraditório, ainda foi possível das testemunhas, as quais confirmaram que o acusado era conhecido nos meios policiais pela prática de roubo contra mulheres, com o mesmo *modus operandi*.

É correto afirmar que existem indícios de que o acusado realmente participou da empreitada criminosas.

Entretanto, as provas constantes dos autos não são suficientes para ensejar a condenação do réu.

Registre-se que mesmo havendo indícios de que suposto crime tenha sido perpetrado pelo réu, estes não atingiram o status de prova segura, até porque, em Juízo, a vítima não o reconheceu.

Por outro lado, a prova produzida na fase de inquérito não tem aptidão para sustentar uma condenação. Uma vez iniciada a ação penal, as provas ontologicamente repetíveis coletadas na fase inquisitorial não servem para fundamentar a condenação, pois são uma prova precária produzida em sede policial sem o contraditório. A prova produzida na fase inquisitorial serve tão somente para subsidiar o convencimento do órgão de acusação e permitir o oferecimento da denúncia, salvo se irrepetível. O Poder Judiciário existe e justifica-se em função da garantia à Jurisdição: como seu consectário lógico, exsurge a garantia de ser julgado com base na prova produzida dentro do processo, com todas as garantias do devido processo penal.

São atos de prova os atos dirigidos a convencer o juiz de uma afirmação para o julgamento final, no processo e a serviço do processo e da sentença, exigindo a estrita observância à publicidade, contraditório e imediação, praticados sob a visão e a supervisão do Juiz de Direito. Por outro lado, são atos de investigação aqueles dirigidos não a uma afirmação, mas a uma hipótese; estão a serviço da investigação preliminar e servem para formar um juízo de probabilidade – não a convicção do juiz; não exigem observância da publicidade, contraditório e imediação, princípios que podem ser restringidos; servem à formação da opinião *delicti* da acusação, demonstrando o *fumus commissi delicti* para justificar o processo (recebimento da ação penal) ou o não processo (arquivamento) e são praticados pelo Ministério Público ou polícia judiciária. São os atos de prova que podem fundamentar uma condenação, mas não os atos de investigação.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em decisão que se aplica analogamente ao caso em tela: “Importa registrar que a prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal.

Assentir com entendimento contrário implicaria considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente. Ou seja, significaria inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais. Assim, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial, mormente quando essa prova está isolada nos autos” (AgRg no REsp 1740921/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Quinta Turma, j. 06/11/2018).

Em que pese eventual gravidade dos fatos imputados, isto não é razão suficiente para assumir o risco do erro judiciário em que consistiria a condenação no presente caso, pois o conjunto probatório é demasiadamente frágil. Nisto consiste o mandamento de otimização contido no princípio do *in dubio pro reo*. Em um modelo garantista, em que devem ser respeitados os princípios e garantias da pessoa submetida ao processo penal a fim de evitar abusos estatais que interfiram em sua liberdade, dúvidas consideráveis devem ser resolvidas favoravelmente ao réu. Assim ensina LUIGI FERRAJOLI, ao concluir que “A certeza perseguida pelo direito penal mínimo está, ao contrário, em que nenhum inocente seja punido à custa da incerteza de que também algum culpado possa ficar impune” (Direito e Razão. São Paulo:

Revista dos Tribunais, 2002, p. 85).

Ante o fundamentado e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o mérito da ação penal e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para ABSOLVER, na forma do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, o acusado WILLIAN DE OLIVEIRA FERREIRA da imputação do cometimento de crime descrito na denúncia (art. 157, "caput", c.c art. 61, inciso II, "j" (calamidade pública), ambos CP).

REVOGO a prisão preventiva. Expeça-se, de imediato, alvará de soltura clausulado. Comunique(m)-se ao(s) ofendido(s) a presente sentença, na forma do art. 201, § 2º do Código de Processo Penal.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Oportunamente, elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diligências necessárias. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

Cruzeiro, 02 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA